InDret

Strukturen eines europäischen Haftungsrechts

Geschichtliche Entwicklung und moderne Dogmatik

Nils Jansen
Universität Regensburg

Working Paper Nr.: 128
Barcelona, April 2003
www.indret.com

Zusammenfassung[1]

1. Thema
2. Bolton v Stone
3. Probleme der Zweispurigkeit
3.1. Die Einheitlichkeit des Haftungsrechts und die Uneinheitlichkeit europäischer Regelungen
3. 2. Die Einheitlichkeit haftungssteuernder Wertungen
4. Gründe für die Zweispurigkeit
4. 1. Bürgerliche Verhaltenspflichten
4. 2. Ausgleich und Verteilung
5. Eine historische Erklärung
5.1. Zur Entstehung des Haftungsrechts aus dem römischen Deliktsrecht
5.2. Auf dem Weg zu einem modernen Haftungsrecht
5.3. Das Haftungsrecht in der naturrechtlichen Diskussion
5.4. Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert
6. Ein alternatives Modell

1. Thema

Das grundlegende Strukturprinzip des heutigen Haftungsrechts besteht in seiner „Zweispurigkeit", also in der Gliederung in das Deliktsrecht einerseits und in fehlverhaltensunabhängige Haftungstatbestände andererseits[2]. Danach soll die deliktische Haftpflicht auf einem Fehlverhalten beruhen: Der Schädiger muß für einen Schaden einstehen, weil er sich pflichtwidrig verhalten, also eine „unerlaubte Handlung" begangen hat; dogmatisch wird das mittels der Begriffe der Rechtswidrigkeit und der Schuld beschrieben. Auf grundsätzlich anderen Gründen sollen demgegenüber die Tatbestände fehlverhaltensunabhängiger Haftungen, wie die Gefährdungs- und die Aufopferungshaftung, beruhen: Der Schädiger haftet hier unabhängig von einem Fehlverhalten, so daß für die Begründung eines Anspruchs kategorial andere Gründe erforderlich sein sollen; insbesondere sind dies die Gefährlichkeit des schädigenden Verhaltens sowie die absichtliche Inanspruchnahme fremder Rechtsgüter[3].

---

[1] Der Aufsatz bildet die ausformulierte Version eines Vortrags am Hamburger MPI für ausländisches und internationales Privatrecht. Er beruht in wesentlichen Teilen auf meiner *Struktur des Haftungsrechts. Geschichte, Theorie und Dogmatik außervertraglicher Ansprüche auf Schadensersatz* (erscheint demnächst bei Mohr Siebeck, Jus Privatum). Nachweise bleiben daher auf das Wichtigste beschränkt.

[2] *J. Esser*, Die Zweispurigkeit unseres Haftpflichtrechts, JZ 1953, S. 129 ff.

[3] *E. Deutsch*, Allgemeines Haftungsrecht[2], 1995, Rn. 5, 8, 9, 13, 14 und öfter; *K. Larenz/C.-W. Canaris*, Lehrbuch des Schuldrechts II/2, 1994, S. 351 f., 605. Auf dieser Annahme beruht auch der Entwurf der *Study Group on a European Civil Code* um *Christian von Bar*; dazu *Jansen* (Fn. 1), § 9 I. 4.1 m.w.N.

Diese grundlegende Unterscheidung findet sich heute in sämtlichen europäischen Rechtssystemen und sie nimmt auch in der ökonomischen Analyse einen zentralen Platz ein[4]; sie scheint also ein allgemeines Strukturprinzip des europäischen Haftungsrechts zu bilden. Freilich ist sie in anderen Ländern dogmatisch wesentlich weniger deutlich ausgeprägt als im deutschen Recht. Denn nur dieses sieht darin mehr als ein nützliches Ordnungsprinzip und hat dieses mit einer entsprechenden gerechtigkeitstheoretischen Grundlegung teleologisch aufgewertet[5]. Konzeptionell scheint die Zweispurigkeit aber überall eine Selbstverständlichkeit zu bilden. Entsprechend halten auch die Vorschläge für ein künftiges europäisches Recht begrifflich und gedanklich an Zweispurigkeit fest, indem sie Haftungstatbestände wegen eines Fehlverhaltens, insbesondere die Fahrlässigkeitshaftung, systematisch strikt von der strikten Gefährdungshaftung trennen[6].

Die Hauptthese dieses Beitrags lautet, daß die Unterscheidung verfehlt ist und deshalb aufgegeben werden sollte. Tatsächlich ist das Haftungsrecht nämlich einheitlich strukturiert. Die „Zweispurigkeit" verdeckt daher mehr an Wertungszusammenhängen als sie dogmatisch strukturieren könnte. Dies bedeutet freilich nicht, daß rechtswidriges Verhalten nicht als solches einen Grund für Haftung bilden könne. Das Gegenteil ist der Fall: § 823 II BGB bildet ein geradezu klassisches Beispiel. Im folgenden soll diese Haftung *allein* wegen eines Fehlverhalten allerdings nicht das Thema sein[7]. Denn entscheidend ist, daß zwischen dem übrigen Teil des Deliktsrechts, insbesondere also dem zentralen § 823 I BGB bzw. der englischen *negligence*-Haftung oder § 1382 *Code civil* einerseits, und Tatbeständen einer strikten Haftung andererseits kein struktureller Unterschied besteht: Jeweils handelt es sich um eine Haftung für zurechenbare, persönlich zu verantwortende Rechtsgutsbeeinträchtigungen.

Dabei zielt, dies ist vorab zu betonen, die These nicht auf eine inhaltliche Änderung des Rechts, sondern es geht allein um die Frage nach Möglichkeiten einer adäquaten Beschreibung des tatsächlich geltenden Rechts. Eine solche adäquate Reformulierung ist allerdings insbesondere auch in Hinblick auf eine künftige Kodifizierung des Haftungsrechts von grundsätzlicher Bedeutung. Denn eine wertungsadäquate Beschreibung des Rechts ist erforderlich, um inkonsistenten Entscheidungen von Gerichten vorzubeugen.

2. Bolton v Stone

Die englische Entscheidung *Bolton* v *Stone*[8] kann die Probleme einer zweispurigen Gliederung des Haftungsrechts besonders anschaulich illustrieren. Dabei steht die Entscheidung für die Frage, worum es bei der Fahrlässigkeit wertungsmäßig eigentlich gehen müßte, nämlich um die im zwischenmenschlichen Verkehr vernünftigerweise zu fordernde Sorgfalt; insoweit gilt die

---

[4] Ausführlicher dazu *Jansen* (Fn. 1), § 3 I. 1.; auch aus ökonomischer Perspektive kann aber eine graduell abgestufte Haftung „zwischen" den Tatbeständen der Haftung für ein Fehlverhalten und der strikten Haftung ausgesprochen sinnvoll sein: a.a.O., § 3 I. 1.3.3.

[5] Dazu unten IV. 2.

[6] *C. v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I, 1996, Rn. 5 ff.; Bd. II, 1999, Rn. 179, 244, 278; siehe auch *dens.*, Konturen des Deliktsrechtskonzepts der Study Group, ZEuP 9 (2001), S. 515, 526; ebenso *G. Wagner*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, erscheint in: *R. Zimmermann* (Hg.), Grundstrukturen eines Europäischen Deliktsrechts, Arbeiten zur Rechtsvergleichung (Nomos), 2003, V. 1.c.

[7] Siehe noch unten bei Fn. 134.

[8] [1951] AC 850 (H.L.)

Entscheidung in England heute als ein „Schulfall“: Studenten lernen, daß bei der Fahrlässigkeit allein danach zu fragen sei, ob das schädigende Verhalten *reasonable*, also pflichtgemäß war. Es komme gerade nicht darauf an, ob der in Frage stehende Schaden *foreseeable* war[9].

Frau *Bessie Stone*, dies bildet den Sachverhalt der Entscheidung, stand auf dem *highway* vor ihrem Haus, während auf dem benachbarten Kricketfeld ein Spiel stattfand. Ein außerordentlich gelungener Schlag von 103 *yards* trug die Kugel über den Sicherheitszaun und verletzte Frau *Stone* erheblich. Im anschließenden Prozeß machte der beklagte Verein nun geltend, daß ihm keine Sorgfaltswidrigkeit vorzuwerfen sei. Der Zaun sei hoch genug gewesen, um die allermeisten Kugeln abzufangen. Während der letzten 30 Jahre seien nur sechs Kugeln über den Zaun geschlagen worden; zudem sei die anliegende Straße normalerweise nicht belebt. Entsprechend habe sich in der 85jährigen Geschichte des Vereins bislang auch kein vergleichbarer Unfall ereignet. Einen höheren Zaun zu errichten, sei deshalb *unreasonable* dürfe dem Verein folglich nicht angesonnen werden.

Eine solche Argumentation ist unmittelbar einleuchtend und scheint deshalb ausgesprochen plausibel; auch die *Study Group on a European Civil Code*, die sich unter der Leitung von *Christian von Bar* um die Formulierung eines gemeineuropäischen Bürgerlichen Rechts bemüht, hat sich deshalb in Art. 1: 103 der Haftungsprinzipien diesen Standpunkt zu eigen gemacht[10]. Gleichwohl darf aber gefragt werden, warum denn eigentlich Frau *Stone* die Kosten tragen soll, die aus der Perspektive des Vereins gerechtfertigt sind. Warum, so läßt die Frage sich präzisieren, darf der Verein seine Kosten externalisieren, solange diese nur gering sind? Betrachtet man den Fall in dieser Weise, so erscheint der Gerechtigkeitsgehalt der klageabweisenden Entscheidung deutlich weniger einsichtig als ihre vordergründige Rationalität[11].

Nun berichten englische Juristen vom Hörensagen, daß die Richter und die *barrister* des Vereins sich vor dem Urteil einig gewesen seien, daß der Verein – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht – den Schaden tragen werde. In Deutschland steht den Juristen ein derartig pragmatischer Weg, dogmatische Folgerichtigkeit und Entscheidungsgerechtigkeit in Einklang zu bringen, nicht zu Gebote. Richter müssen deshalb in vergleichbaren Fällen entscheiden, daß beispielsweise Fußballvereine „sicherzustellen“ haben, daß die Fenster der Nachbarn nicht eingeschossen werden – die (ohnehin strengen) Din-Normen seien insoweit nur eine „Mindestempfehlung“[12]. Als tatsächliche Verhaltensanforderung vermag das indes nicht einzuleuchten: Fußbälle sind wesentlich ungefährlicher als Kricketkugeln, die – der Fall von Frau *Stone* macht das anschaulich – einen deutlich größeren Schaden anrichten können als ein Fußball. In der Sache handelt es sich offenbar um eine Art „deliktischer Garantiehaftung“, also um eine fehlverhaltensunabhängige Haftung auf der Grundlage eines deliktischen Haftungstatbestandes. Die herrschende Lehre lehnt dies – dogmatisch folgerichtig – ab. Sie fordert einen Ausbau der Gefährdungs-[13] bzw. der Sachhaftung[14]

---

[9] *B.S. Markesinis & S.F. Deakin*, Tort Law[4], 1999, S. 167 f.

[10] Vgl. *v. Bar*, Konturen des Deliktsrechtskonzept der Study Group (Fn. 6).

[11] Man kann dies abstrakt als die Frage nach dem Gerechtigkeitsgehalt der *Kaldor Hicks*-Effizienz zwischen Privatpersonen diskutieren; allerdings soll das hier nicht geschehen, weil es für das konkrete rechtliche Problem unmittelbar nichts beiträgt.

[12] Staudingers Kommentar zum BGB[13]-*Hager*, § 823, Rn. E 337 mit umfangreichen w.N.

[13] Nach den (mir nicht zugänglichen) Referaten von *Deutsch* und *Weitnauer* auf dem Karlsruher Forum 1968 insbesondere *H. Kötz*, Haftung für besondere Gefahr, AcP 170 (1970), S. 1, 19 ff., 22 ff. m.w.N.; *M.R. Will*, Quellen erhöhter Gefahr, 1980, S. 277 ff.; heute etwa *v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn. 6), Rn. 350; *Wagner* (Fn. 6), V. 3. und 4.; ansatzweise auch *Larenz/Canaris*, SchuldR II/2 (Fn. 3), S. 602; weitere Nachweise bei *Brüggemeier*,

einerseits und eine Beschränkung der Fahrlässigkeitshaftung andererseits[15]. Dies sei erforderlich, so etwa *von Bar*, um die „Funktionsfähigkeit der Fahrlässigkeitshaftung" zu erhalten[16].

Daß die Frage nach pflichtgemäßem Verhalten im Haftungsrecht zu derartigen Schwierigkeiten führen kann bildet dabei keinesfalls ein spezifisch englisches Problem: Obwohl deutsche Richter offenbar weniger Zurückhaltung an den Tag legen, Verkehrspflichten allein zum Zwecke einer Haftungsbegründung zu kreieren, finden sich auch im deutschen Recht vergleichbare Bolton-Entscheidungen. Beispielsweise hat der BGH 1995 entschieden, daß die Unzumutbarkeit, von der Schädigung eines anderen abzusehen, einen Haftungsanspruch nach § 823 I BGB mangels Verschulden ausschließen könne[17]. Konkret ging es um die Anzeige der geplanten Republikflucht eines Verwandten: Der Beklagte hatte die Rolle eines Lockspitzels übernommen, um seinen Onkel zu überführen und ihm einen beabsichtigten ungesetzlichen Grenzübertritt in einem besonders schweren Fall nachzuweisen. Zu einer derartigen Lockspitzeltätigkeit bestand aber auch nach dem Recht der DDR keine Verpflichtung; mehr als eine einfache Anzeige, die zu einer Verurteilung wegen eines beabsichtigten ungesetzlichen Grenzübertritts in einem einfachen Fall geführt hätte, war nicht gefordert. Möglicherweise, so der BGH, war der Beklagte aber damals derart in das System der Staatssicherheit verstrickt, daß es für ihn persönlich unzumutbar war, sich anders zu verhalten.

Wieder entsteht damit dasselbe Problem wie in der Entscheidung *Bolton* v *Stone*: Auf der Ebene der Verhaltensmaßstäbe kann das Verständnis für eine Spitzeltätigkeit unter den besonderen Umstände des Systems der DDR durchaus angezeigt sein. Daß deshalb der Schädiger aber auch den erheblichen, eigennützig verursachten, materiellen Schaden (konkret: den aufgrund des Aufenthalts im Gefängnis entgangenen Verdienst) auf sein Opfer abwälzen darf, vermag doch nicht einzuleuchten. Die Vermutung liegt deshalb nahe, daß die Zweispurigkeit des Haftungsrechts, wonach es für die deliktische Haftung allein auf die Pflichtgemäßheit des schädigenden Verhaltens ankommt, teleologisch in die Irre führt.

3. Probleme der Zweispurigkeit

3. 1. Die Einheitlichkeit des Haftungsrechts und die Uneinheitlichkeit europäischer Regelungen

Im Gegensatz zur kategorischen strikten Aufspaltung des Haftungsrechts in einzelne Haftungsgruppen durch die dogmatische Theorie ist die Rechtswirklichkeit heute durch fließende Übergänge zwischen den einzelnen Haftungen gekennzeichnet. Für eine praktisch hilfreiche Gliederung des Haftungsrechts – dies ist meine zweite These – gibt die Unterscheidung des Deliktsrechts von fehlverhaltensunabhängigen Haftungen deshalb nichts her.

Gesellschaftliche Schadensverteilung und Deliktsrecht, AcP 182 (1982), S. 385, 401 f. Auch der Vorentwurf für eine schweizerische Gesamtrevision des Deliktsrechts hat sich jetzt diese Forderung zu eigen gemacht (Art. 50 VE, leicht zugänglich bei *D. Koch*, Die Gesamtrevision des schweizerischen Haftpflichtrechts, ZEuP 9 (2001), S. 753, 758 ff.); zur Begründung *P. Widmer & P. Wesener*, Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts. Erläuternder Bericht, 2001, S. 137 ff.

[14] *B.A. Koch*, Die Sachhaftung. 1992.

[15] Zu den Problemen einer solchen Konzeption ausführlicher *Jansen* (Fn. 1), § 9 I. 3.3

[16] *v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn. 6), Rn. 313 (S. 343).

[17] BGHZ 127, 195.

Daß insoweit zwischen der Verschuldens- und der Gefährdungshaftung graduelle Übergänge bestehen, bildet dabei keine Neuigkeit[18]. Im deutschen Recht zeigen sich diese insbesondere bei der Fahrlässigkeitshaftung. Die Rechtsprechung hat hier besonders strenge Verkehrspflichten aufgestellt, so daß die „Verschuldenshaftung" hier häufig in der Sache für eine mehr oder weniger strikte Garantiehaftung steht. Interessanterweise gilt das – darauf ist bereits hier hinzuweisen – nicht nur bei besonders gefährlichen Tätigkeiten: Auffallend strikt ist beispielsweise die Haftung des Gastwirts für den Zustand seiner Wirtschaft bzw. die Haftung für Unfälle in Supermärkten[19]. Ähnliches gilt für die Verpflichtung zum Schneeräumen: Hier schadet nicht einmal ein plötzlicher Krankheitsfall, der einen Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich macht: Der Verkehrspflichtige hätte insoweit Vorsorge treffen „müssen"[20]. Wenn Wasser aus Geschirrspül- oder Waschmaschinen ausläuft, hat der Betreiber praktisch für die Mangelfreiheit der Maschine und einen gefahrfreien Betrieb einzustehen[21]. Und ein Reiseveranstalter hatte (deliktisch) die Sicherheit des Hotels zu garantieren; konkret ging es um eine instabile Balkonbrüstung in einem ausländischen Vertragshotel[22]. Ergänzt wird diese Verschärfung von Sorgfaltsanforderungen durch prozessuale Instrumente, wie eine Beweislastumkehr für das Verschuldenserfordernis, die im Ergebnis ebenfalls die Auferlegung einer strikten Haftung bedeuten kann.

Umgekehrt läßt die strenge Gefährdungshaftung sich durch graduell abgestufte Haftungsausschlußtatbestände, wie die höhere Gewalt und das unabwendbare Ereignis, einschränken und damit an die Fahrlässigkeitshaftung annähern. Wenn dabei das unabwendbare Ereignis – entsprechend den älteren subjektiven Theorien zur höheren Gewalt – mittels des „Sorgfaltsstandards" eines „Idealfahrers" beschrieben wird, kann dies im Ergebnis einer besonders strengen Fahrlässigkeitshaftung entsprechen[23]. Zwar hat der Gesetzgeber jetzt für den Straßenverkehr diesen Ausschlußtatbestand zugunsten des objektiven, schärferen Maßstabes der höheren Gewalt abgeschafft; doch ist dies primär aus abstrakt „dogmatischen" Gründen geschehen, die sich dabei jedoch auf dem Stand der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts befinden[24].

Dieser Befund der wechselseitigen funktionalen Ersetzbarkeit des Deliktsrechts und der Gefährdungshaftung wird insbesondere auch durch die Rechtsvergleichung bestätigt[25]. So entspricht die französische *gardien*-Haftung, die konzeptuell eine strikte Haftung für Sachgefahren bedeutet, sowohl tatbestandlich als auch in den Rechtsfolgen der deutschen deliktischen Verkehrspflichtenhaftung[26]. Demgegenüber ist die Kfz-Haftung in England nach dem

---

[18] Zu den fließenden Übergängen zwischen den Verkehrspflichten und der Gefährdungshaftung im deutschen Recht siehe bereits *J. Esser*, Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung[2], 1969, S. 23 ff.; *E. v. Caemmerer*, Reform der Gefährdungshaftung, 1971, S. 13; heute insbesondere *C. v. Bar*, Verkehrspflichten, 1980, S. 103 ff., 128 ff.; *H. Koziol*, Ein europäisches Schadenersatzrecht – Wirklichkeit und Traum, JBl. 2001, S. 29, 35 ff.; *T. Möllers*, Rechtsgüterschutz im Umwelt- und Haftungsrecht, 1993, S. 114 ff.; *E. Steffen*, Haftung im Wandel, ZVersWiss. 82 (1993), S. 13, 18, 20 ff., 25, 27 f.; w.N. bei *Jansen* (Fn. 1), § 9 I 3.1.
[19] *BGH* NJW 1985, 482 f.; NJW 1991, 921 f.; *OLG Köln*, VersR 1999, 243 ff. m.w.N.
[20] *BGH* VersR 1970, 182.
[21] Nachweise unten Fn. 36, 37.
[22] BGHZ 103, 298, 305 f.
[23] Ausführlicher *Jansen* (Fn. 1), § 9 V. 2. und 3.
[24] Ausführlich *Jansen*, Tagespolitik, Wertungswandel und Rechtsdogmatik. Zur Reform des Schadensersatzrechts 2002, erscheint demnächst in der Juristenzeitung.
[25] *v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn. 6), Rn. 244, 306, 313 m.w.N.
[26] *U. Hübner*, Zur Problematik der „Verkehrssicherungspflichten" im französischen Recht, VersR 1980, S. 795 ff.; *v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht (Fn. 6), Bd. I, Rn. 98 ff., 106, Bd. II, Rn. 244, 306, 313, 315 ff., 322 f.

Verschuldensgrundsatz geregelt; weniger streng als in Deutschland ist sie nicht[27]. Umgekehrt würde die Haftung für auslaufende Wasch- oder Geschirrspülmaschinen in England unproblematisch als eine strikte Haftung aus *nuisance* entschieden[28] – mit demselben Ergebnis wie in Deutschland. Entsprechend kennen manche Rechtsordnungen auch genuine Zwittertatbestände, deren Zuordnung zum Deliktsrecht oder zur Gefährdungshaftung sich als besonders schwierig erweist. Insbesondere sind das die strikte Haftung für gefährliche Tätigkeiten im italienischen und portugiesischen Recht[29]; ähnliche Schwierigkeiten stellt aber auch die Haftung für fehlerhafte Produkte in Deutschland[30].

Derartig fließende Übergänge bestehen aber nicht nur zwischen der Verschuldens- und er Gefährdungshaftung, sondern insbesondere auch zwischen der Verschuldens- und der Aufopferungshaftung. Der typische Fall einer Aufopferungshaftung setzt nach deutschem Recht einen vorsätzlichen und berechtigten Eingriff im Sinne des § 904 S. 2 BGB voraus. Hofft der Schädiger, er könne den Schaden vermeiden, so muß das folglich die Haftung entfallen lassen[31]. Wertungsmäßig vermag eine solche Differenzierung freilich nicht einzuleuchten, denn gleichermaßen geht es um eine bewußte, eigennützig motivierte Schädigung. Entsprechend bildet im amerikanischen Recht eine solche Konstellation den klassischen Fall für das Aufopferungsproblem: Ein Schiff hatte wegen eines drohenden Sturms an ein fremdes Dock angelegt und war dazu in seiner Notlage auch befugt. Das Dock wurde sodann von dem Schiff beschädigt, als dieses von Wind und Wellen dagegen geschlagen wurde. Das Gericht stellte unmißverständlich klar, daß die Berechtigung zum Andocken nicht von der Haftung entbinden könne[32]: Wer fremde Rechtsgüter – sei es durch einen direkten Zugriff, sei es durch eine bewußte, eigennützige Gefährdung – in Anspruch nimmt, hat den eventuell Geschädigten zu entschädigen. Entsprechend gilt jetzt nach dem neuem niederländischem Recht, daß ein gewichtiges öffentliches Interesse den Unterlassungsanspruch gegen eine schädigende Handlung ausschließen kann, daß dies aber einen eventuellen Schadensersatzanspruch unberührt läßt (Art. 6: 168 I BW); konkret wurde dies bei der Betriebsblockade eines Chlorproduzenten durch Greenpeace-Aktivisten bejaht[33].

Die normative Grundlage derartiger Regeln und Entscheidungen findet sich dabei in der verhältnismäßig einfachen Überlegung, daß der Ausgleich konfligierender Interessen sich bisweilen nicht befriedigend regeln läßt, indem einem Interesse pauschal der Vorrang gegenüber einem anderen eingeräumt wird, so daß die entsprechende Tätigkeit verboten wird bzw. eine Störung durch die andere ohne weiteres hinzunehmen hat. Wesentlich interessengerechter kann es nämlich sein, einer Partei die Beeinträchtigung der Interessen der anderen zu gestatten, sofern sie diese

---

[27] Siehe etwa *Roberts* v *Ramsbottom* [1980] 1 All ER 7: ein Schlaganfall, der zur vollständigen verstandesmäßigen Steuerungsunfähigkeit führe, entschuldige einen Verkehrsunfall nicht, solange der Fahrer noch imstande sei, Bewegungen auszuführen.

[28] Vgl. *J. Fleming*, The Law of Torts[9], 1998, S. 457; *Sedleigh-Denfield* v *O'Callagham* [1940] AC 880 (H.L.): Wasserüberflutung aufgrund eines verstopften Abflußrohres.

[29] Art. 2050 ital. Cc; art. 493 Abs. 2 port. Cc.

[30] *P. Marburger*, Grundsatzfragen des Haftungsrechts unter dem Einfluß der gesetzlichen Regelungen zur Produzenten- und zur Umwelthaftung, AcP 192 (1992), S. 1, 10 ff.

[31] *Larenz/Canaris*, SchuldR II/2 (Fn. 3), S. 668; *E. Deutsch*, Die Unzumutbarkeit als Entschuldigungsgrund, FS H. Stoll, 1999, S. 3, 9; vgl. auch BGHZ 92, 357, 359 ff. zum Ausweichmannöver im Straßenverkehr.

[32] *Vincent* v *Lake Erie Transp. Co.* 124 NW 221 (1910) (Supreme Court of Minnesota); der Fall wurde dabei auf der Grundlage der allgemeinen *negligence*-Haftung entschieden.

[33] *Rechtsbank Roermund* KG 1993 Nr. 411, S. 824.

schadlos stellt[34]. Entsprechend hatte ein niederländisches Gericht schon früher entschieden, daß es einem Autohersteller unter Umständen nicht zuzumuten sei, sämtliche Zulieferteile auf ihre Funktionstätigkeit zu überprüfen; daß er aber wirtschaftlich auf eigene Gefahr zu handeln habe, wenn er das unterlasse[35]. Ebenso wurde in den Waschmaschinenfällen in Deutschland ursprünglich entschieden, daß es einer Hausfrau nicht wirklich angesonnen werden könne, ihre Maschinen ununterbrochen zu bewachen; es sei aber selbstverständlich, daß sie zu haften hätten, wenn sie das unterließen[36]: Der Geschädigte erhält wenigstens einen Ausgleich – dies macht die Gefährdung seiner Rechtsgüter akzeptabel; und die Hausfrau darf ihre Wohnung verlassen – wenn auch um den Preis der Risikotragung.

Heute begründen Gerichte die Haftung in diesen Fällen mit der Behauptung tatsächlicher Verkehrs- also Verhaltenspflichten[37]; plausibel ist das indes nicht[38]. Daß derartige Fälle eine Haftung für ein Fehlverhalten bedeuten sollen, vermag deshalb nicht einzuleuchten. Offenbar ist eine klare Grenzziehung zwischen der Haftung für ein Fehlverhalten und der Gefährdungs- bzw. der Aufopferungshaftung hier nicht möglich. Jeweils scheint die Haftung – unabhängig von der Erlaubnis des schädigenden Verhaltens – darauf zu beruhen daß der Schädiger bewußt und eigennützig eine unausweichliche Gefahr für den Geschädigten geschaffen hat.

3. 2. Die Einheitlichkeit haftungssteuernder Wertungen

Offenbar beruhen Haftungsentscheidungen auf der Grundlage des Deliktsrechts und fehlverhaltensunabhängige Haftungstatbestände häufig auf identischen normativen Erwägungen; diese teleologische Geschlossenheit des Haftungsrechts bildet das entscheidende Argument dafür, dessen gegenwärtige „zwei-“ bzw. „mehrspurige“ dogmatische Gliederung zu überwinden. Gerichte fragen nicht nur, ob der Schädiger sich ordnungsgemäß verhalten habe: daneben steht immer auch die Frage, wer welche Risiken tragen solle. Dies bildet den Grund dafür, daß auch Entscheidungen auf der Grundlage des Deliktsrechts regelmäßig von Überlegungen gesteuert sind, die dogmatisch für die Gefährdungshaftung spezifisch sein sollen: Das Haftungsrecht entscheidet ganz allgemein, wer welche Risiken tragen soll.

Nun unterliegen dabei aber häufig auch Verhaltensweisen, die gerade nicht besonders gefährlich sind, einer besonders strikten Haftung; die oben gebotenen Beispiele zeigen das deutlich: Wirtschaften, Supermärkte und (auch ungeräumte) Gehwege[39] sind ebensowenig gefährlich wie Geschirrspül- und Waschmaschinen. Die tragenden Wertungen für diese Entscheidungen können sich deshalb nicht in einer Beurteilung der schädigenden Tätigkeiten finden, sondern nur in der Schutzwürdigkeit der davon betroffenen Interessen. Strukturell beruht das auf dem *Symmetriecharakter* von Haftungsentscheidungen[40]: Soweit es im Haftungsrecht um die faire, akzeptable Verteilung von Schadensrisiken geht, kann es nicht allein auf eine Beurteilung der

---

[34] Ausführlicher *Jansen* (Fn. 1), § 1 III. 1. und 2.
[35] *Hof Amsterdam* NedJur 1958, Nr. 104, S. 297.
[36] *OLG Düsseldorf* VersR 1975, 159 f.
[37] Siehe etwa *OLG Hamm* MDR 1984, 668; *LG Gießen* VersR 1997, 1023 m.w.N.: Der Betreiber habe an der Maschine „in kürzeren Abständen optische und akustische Überwachungen“ vorzunehmen.
[38] *N. Jansen*, Das Problem der Rechtswidrigkeit bei § 823 Abs. 1 BGB, AcP 202 (2002), S. 517, 528.
[39] Hier stellt die Rechsprechung ganz allgemein besonders strenge Anforderungen und akzeptiert normalerweise nur sehr geringe Bodenunebenheiten:
[40] *Jansen* (Fn. 1), § 1 III. 3.

Tätigkeit des Schädigers ankommen, wie dies von der heutigen schädigerzentrierten Dogmatik sowohl beim Deliktsrecht als auch bei der Gefährdungshaftung vorausgesetzt wird. Ebenso ist zu fragen, welche Tätigkeiten von einer Schädigung typischerweise betroffen sind und in wie weit diese Schutz verdienen. Entsprechend werden Alltagstätigkeiten heute offenbar besonders geschützt[41]; gerade auch das zeigen die Beispiele deutlich: Es ging um den Besuch einer Wirtschaft bzw. eines Supermarktes, um das Gehen auf dem Bürgersteig und um das Bewohnen einer Wohnung. Umgekehrt werden Wirtschaftsunternehmen in einem besonderen Maße belastet[42]. Im *common law* ist darüber hinaus sogar ein deutliches Bestreben zu spüren, Unterprivilegierte haftungsrechtlich zu entlasten; deshalb wird beispielsweise der Lebenswandel von Müttern – auch zur Vermeidung eines Anreizes für Abtreibungen – nicht als Pflichtverletzung konzeptualisiert[43].

Entscheidend ist also die Zumutbarkeit bzw. Angemessenheit, eine Tätigkeit auf *eigene Gefahr* unternehmen zu *müssen*, wobei die Gründe dafür insbesondere in einer besonderen Eigennützigkeit bestehen können; eine notstandsgerechtfertigte Gefährdung fremder Rechtsgüter bietet dafür geradezu einen typischen Fall. Freilich gilt dabei nicht einfach der Satz, daß wer ein Risiko setze, dieses als eigenes haftungsrechtlich zu verantworten habe: Unfälle entstehen ja typischerweise aufgrund von Aktivitäten des Schädigers *und* des Geschädigten, die ihren Interessen normalerweise gleichermaßen im Eigeninteresse nachgehen: Wer ein Kaufhaus aufsucht, obgleich er schon etwas schwach auf den Beinen ist, tut dies gemeinhin ebenso im Eigeninteresse, wie der Pächter des Ladens diesen betreibt.

Umgekehrt kann deshalb auch die potentiellen Geschädigten eine besondere Verantwortlichkeit bezüglich bestimmter Risiken treffen: Vielleicht können sie bestimmten Gefahren besonders einfach vorbeugen; vielleicht müssen sie sich sagen lassen, daß sie bestimmte, besonders empfindliche Sachen einer Gefährdung ausgesetzt hätten; vielleicht war für den Geschädigten auch einfach eine Sachversicherung einfacher oder günstiger erhältlich als es die Haftpflichtversicherung für den Schädiger gewesen wäre. Dies kann einen Grund dafür bilden, den Geschädigten mit einer Versicherungsobliegenheit zu belasten und das entsprechende Schadensrisiko deshalb seinem Verantwortungsbereich zuzuweisen[44].

Teleologisch scheint also nach allem keine Unterschiede zwischen Tatbeständen einer strikten Haftpflicht und der Haftung für ein Fehlverhalten zu bestehen. Jeweils beruht eine konkrete Haftungsentscheidung offenbar auf einer Vielzahl abwägungsfähiger und -bedürftiger Kriterien[45]. Da die Dogmatik des Haftungsrechts, die allein auf ein Fehlverhalten bzw. eine besondere Gefahr abstellt, für derartige Kriterien keinen Raum bietet, können Richter ihre letztlich haftungstragenden Überlegungen nur in seltenen Ausnahmefällen benennen[46]. Soweit kein spezieller

---

[41] *Jansen* (Fn. 1), § 9 VI. 3.2.

[42] *Jansen* (Fn. 1), § 9 VI. 3.1 m.w.N.

[43] *J. Stapleton*, Duty of Care Factors: a Selection from the Judicial Menus, in: *P. Cane & J. Stapleton* (Hg.), The Law of Obligations, GS Fleming, 1998, S. 59, 87 m.w.N.; konkrete Entscheidungen betreffen etwa den Drogenkonsum von Müttern, der sie nicht zur Haftung gegenüber ihren später geschädigten Kindern verpflichten soll.

[44] Zur Relevanz der besseren Versicherbarkeit für die Zuweisung von Schadensrisiken *Jansen* (Fn. 1), § 2 II. 5.4, § 9 VI. 3.4 m.w.N.

[45] Zur Formulierung eines handhabbaren, intersubjektiv verständlichen „beweglichen Systems“ derartiger Haftungsprinzipien *Jansen* (Fn. 1), § 9 IV. – VI.

[46] Angesichts dessen ist es derzeit auch nicht möglich, eine vollständige Liste der tatsächlich geltenden bzw. der tatsächlich angewendeten Haftungsprinzipien zu formulieren. Welche Überlegungen richterliche Entscheidungen tatsächlich gesteuert haben, läßt sich letztlich nur vermuten. Vgl. auch *Stapleton*, Duty of Care

Gefährdungshaftungstatbestand einschlägig ist, müssen sie stattdessen mißverständlich fragen, wie der Schädiger sich hätte anders verhalten sollen, um den Schaden zu vermeiden. Wenn Richter sich entsprechend gehindert sehen, ihre tatsächlich entscheidungstragenden Erwägungen zu benennen, so muß das dazu führen, daß sich das geltende Haftungsrecht nur noch kasuistisch mittels einer Auflistung einzelner Entscheidungen beschreiben läßt. Zugleich erhöht das aber auch die Gefahr inkonsistenter bzw. wertungsungerechter Entscheidungen wie im Lockspitzelfall. Denn auch Richter verfügen nicht über einen geheimes Haftungssystem, das sie vor dem Rest der Welt verborgen halten.

4. Gründe für die Zweispurigkeit

Dieses einheitliche Bild des Haftungsrechts in der Rechtswirklichkeit schließt freilich keinesfalls die Möglichkeit guter Gründe für eine zweispurige Strukturierung aus: In der Sache ist das einheitliche Bild ein Resultat der Rechtsprechung, und die Rechtsprechung kann sich irren. Es gilt deshalb nach den Gründen zu fragen, die üblicherweise für die Zweispurigkeit angeführt werden.

4. 1. Bürgerliche Verhaltenspflichten

Neben spezifisch ökonomischen Argumenten[47] ist das zum einen die Annahme, daß eine spezifische Aufgabe des Deliktsrechts darin bestehe, einen Katalog bürgerlicher Verhaltenspflichten aufzustellen[48]. Plausibel ist das aber – zumindest heute – nicht mehr. Denn für die tatsächlichen Verhaltensanforderungen finden sich derartig detaillierte Regelungen im öffentlichen Recht, in DIN-Normen und in technischen Regelwerken, daß eine privatrechtliche Ergänzung daneben überflüssig ist. Zudem entscheidet das Haftungsrecht ja immer nur *ex post* und für konkrete Einzelfälle, welche Sorgfalt erforderlich gewesen wäre. Eine solche Verkehrspflichtenrechtsprechung vermag deshalb keinen geeigneten Maßstab für das Verhalten von Menschen zu bieten: Menschen wissen durchaus, daß sie sich im Umgang mit den Rechtsgütern anderer sorgfältig zu verhalten haben; aber die Vorstellung, daß man sein Verhalten dabei an der Rechtsprechung ausrichtet, wie sie sich etwa von *Hager* auf mehreren hundert Seiten zusammengefaßt vorfindet[49], ist weder realistisch noch wünschenswert:

4. 2. Ausgleich und Verteilung

Wichtiger als dieses Argument bürgerlicher Verhaltensregeln ist daher die – auf *Esser*

Factors (Fn. 43), S. 87, die eine abschließende Formulierung überhaupt skeptisch beurteilt.

[47] Vgl. oben Fn. 4: Die herrschende Meinung zur ökonomischen Analyse des Rechts meint, daß „ineffiziente“ Sorgfaltsstandards, die haftungsrechtlich einen höheren Sorgfaltsmaßstab aufstellen, als in Hinblick auf tatsächliches Verhalten ökonomisch sinnvoll ist, gesamtwirtschaftlich ineffiziente Verhaltensanreize setzen; doch beruht dies auf falschen juristischen Voraussetzungen: „Ineffiziente“ Sorgfaltsstandards können ebenso effizient sein wie eine strikte Haftung.

[48] Dieses Argument wird nur selten ausdrücklich formuliert; es wird aber stillschweigend vorausgesetzt, wenn geltend gemacht wird, daß überzogene Sorgfaltsstandards der Präventionsfunktion des Deliktsrechts zuwiderliefen (vgl. etwa Münchener Kommentar BGB[3]-*Mertens*, Vor §§ 823-825, Rn. 57; *Deusch*, Haftungsrecht (Fn. 3), Rn. 18, 246); dem entspricht auch das Argument *v. Bars* zur „Funktionsfähigkeit“ des Deliktsrechts (oben Fn. 16) und seine Ablehnung „überzogener“ Sorgfaltsanforderungen: Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn. 6), z.B. Rn. 224, 244, 278, 284.

[49] Staudinger[13]-*Hager* (Fn. 12), § 823, Rn. E 1-406.

zurückgehende[50] – gerechtigkeitstheoretische These, daß das Deliktsrecht allein der ausgleichenden Gerechtigkeit diene, während die Gefährdungshaftung die Verteilung unvermeidbarer bzw. gesellschaftlich akzeptierter Schadensrisiken betreffe, die die Industrialisierung und der technische Fortschritt mit sich brächten. Dies bildet das häufigste Argument in der deutschen dogmatischen Diskussion[51]; es bedeutet eine wertungsdogmatische Vertiefung der zunächst nur pragmatischen Gliederung. Während sich die deutsche Lehre dabei die prägnanten Thesen Essers zumeist ohne weiteres zu eigen gemacht hat, wird dazu im Bereich des *common law* heute eine intensive, auch für andere Rechtsordnungen interessante Grundlagendiskussion geführt[52].

Der These Essers liegt dabei die Intuition kategorisch verschiedener Gründe der unterschiedlichen Haftungen zugrunde. Danach soll die ausgleichende Gerechtigkeit den Ausgleich zwischen den an einer rechtlich relevanten Interaktion Beteiligten regeln, während die distributive Gerechtigkeit über die Verteilung von Gütern und Lasten innerhalb einer relevanten Gruppe bestimmt. Das Deliktsrecht bildet danach einen Ausdruck der persönlichen Verantwortlichkeit, während die Gefährdungshaftung als eine Art kollektiver Versicherung zu verstehen wäre. Historisch beruht diese These dabei auf einer zutreffenden Beobachtung. Denn die einzelnen Tatbestände der heutigen Gefährdungshaftung wurden in der Tat für Fallgruppen in Geltung gesetzt, in denen die Verschuldenshaftung zu Ergebnissen führte, die man aus sozialen Gründen nicht hinzunehmen bereit war[53].

Nun ist diese aristotelische Unterscheidung kategorial verschiedener Arten von Gründen auch heute für das Verständnis des Haftungsrechts hilfreich; allerdings kann sie die These Essers gerade nicht bestätigen. Denn tatsächlich ist das Haftungsrecht komplexer strukturiert und verlangt eine kombinatorische Konzeption der ausgleichenden und der distributiven Gerechtigkeit – dies bildet meine dritte These. Wird das Haftungsrecht an die ausgleichende Gerechtigkeit gebunden, so bedeutet das nämlich zunächst nicht mehr, als daß ein Haftungsanspruch die persönliche Verantwortlichkeit des Schädigers für den konkreten Schaden voraussetzt: Für Schäden, die man nicht zu verantworten braucht, braucht man – jedenfalls auf der Grundlage der ausgleichenden Gerechtigkeit – nicht einzustehen. Die ausgleichende Gerechtigkeit bildet damit den normativen Rahmen für das Haftungsrecht; dies steht beispielsweise für eine Entscheidung gegen Vorschläge, das Haftungsrecht durch Reformmodelle einer kollektiven Versicherung zu ersetzen.

Mit der Entscheidung, die Haftung an die persönliche Verantwortlichkeit zu binden, ist freilich noch nicht gesagt, wie weit diese reiche; vielmehr sind die Vorstellungen über die Reichweite der persönlichen Verantwortlichkeit sowohl historisch als auch zwischen unterschiedlichen Rechtsbereichen und im Verhältnis zur öffentlichen Moral durchaus verschieden[54]. Beispielsweise

---

[50] *Esser*, Gefährdungshaftung (Fn. 18), S. 69 ff.; *ders*., Zweispurigkeit (Fn. 2).
[51] Siehe insbesondere *Larenz/Canaris*, SchuldR II/2 (Fn. 3), S. 354, 607; ferner *S. Meder*, Schuld, Zufall, Risiko, 1993, S. 209 ff., 274 f.; *A. Laufs*, Unglück und Unrecht. Ausbau oder Preisgabe des Haftungssystems, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 1994, S. 8 ff.; *H.J. Mertens*, Verkehrspflichten und Deliktsrecht, VersR 1980, S. 397, 405.
[52] Ausführlich und m.w.N. *Jansen* (Fn. 1), § 2 I. und II.
[53] *R. Ogorek*, Untersuchungen zur Entwicklung der Gefährdungshaftung im 19. Jahrhundert, 1975, S. 99 ff., 113 ff.; *R. Zimmermann*, The Law of Obligations, paperback ed. 1996, S. 1133 ff.
[54] Vgl. etwa *B. Williams*, Recognizing responsibility, in: *ders.*, Shame and Necessity, 1993, S. 50, 55, 63 ff., 67; *D.J. Ibbetson*, A Historical Introduction to the Law of Obligations, 1999, S. 58 ff., 155 ff., 164 ff.; *Meder*, Risiko (Fn. 51), S. 20 ff., 46 ff.

wäre eine verschuldensunabhängige strafrechtliche Haftung ein Unding; im Zivilrecht wird sie demgegenüber zunehmend selbstverständlich. Eltern brauchen für den Unfug ihrer Kinder von Rechts wegen nicht zu haften; moralisch werden sie sich aber häufig dafür verantwortlich fühlen: Sie werden sich entschuldigen und einen eventuellen Schaden – vielleicht auch unabhängig von einer Rechtspflicht – wieder gutmachen.

Die persönliche Verantwortlichkeit erweist sich damit als ein teleologisch offenes Konzept, das Raum für weitere Wertungen bietet. Diese Wertungen sind nun aber solche der distributiven Gerechtigkeit: Die Entscheidung, für welche Folgen man verantwortlich ist bzw. verantwortlich sein sollte, betrifft die Verteilung einer bestimmten Last, nämlich die Zuordnung von Schadensrisiken, innerhalb einer Gesellschaft: Auch der – scheinbar evidente – Satz, daß man verschuldete Schäden zu verantworten habe, ist in diesem Sinne distributiver Art. Historisch ist dabei auch dieser Satz durchaus nicht selbstverständlich, sondern drückt ursprünglich eine gesteigerte Verantwortlichkeit für mittelbar verursachte Schäden aus[55].

Angesichts dessen müssen haftungsrechtliche Entscheidungen stets eine Wertung der ausgleichenden Gerechtigkeit um distributive Erwägungen ergänzen; insoweit besteht kein Unterschied zwischen der Verschuldenshaftung und strikten Haftungstatbeständen. Einerseits beruht auch die Gefährdungshaftung auf der ausgleichenden Gerechtigkeit: Der Autohalter bzw. der Eisenbahnunternehmer haften auch bei unverschuldeten Schäden nicht ohne, sondern aufgrund ihrer Verantwortlichkeit[56]: Wer einen Verkehrsunfall verursacht, kann diesen angesichts der Vorhersehbarkeit derartiger Unglücke auch dann nicht als einen Zufall abtun, mit dem er nichts zu tun habe, wenn ihm kein persönliches Fehlverhalten trifft; und ebenso können Unternehmen, die einer riskanten Aktivität nachgehen, die Verantwortlichkeit für einen Schadensfall nicht mit dem Argument eines ordnungsgemäßen Betriebs von sich weisen. Andererseits impliziert aber auch die Verschuldenshaftung eine distributive Wertung, nämlich die Beschränkung der Haftungsverantwortlichkeit auf die Folgen eines individuellen Fehlverhaltens. Hinsichtlich der normativen Wertungsstruktur besteht also zwischen der Gefährdungs- und der Verschuldenshaftung kein Unterschied; auch die gerechtigkeitstheoretische Begründung der zweispurigen Strukturierung des Haftungsrechts erweist sich damit als verfehlt.

5. Eine historische Erklärung

Wenn es angesichts all dessen – jedenfalls heute – keine guten Gründe für eine zweispurige Strukturierung des Haftungsrechts zu geben scheint, so liegt es nahe, nach der historischen Erklärung dafür zu suchen: Warum halten die meisten Juristen die Zweispurigkeit für ein selbstverständliches Strukturprinzip, obgleich dieses doch derart viele Probleme mit sich bringt? Meine vierte, historische These lautet hierzu, daß die mit der Zweispurigkeit verbundenen heutigen Schwierigkeiten des Haftungsrechts darauf beruhen, daß die ursprünglich für das römische Deliktsrecht geprägten Begriffe der Rechtswidrigkeit (*iniuria*) und des Verschuldens

[55] *Jansen* (Fn. 1), § 4 II. 3.3.1 zur *culpa* im Römischen Recht.

[56] Nicht zuletzt zeigt sich dies in der Entscheidung des Gesetzgebers, jetzt auch bei der Gefährdungshaftung einen Ersatz immaterieller Schäden zu gewähren: Eine solche Entscheidung läßt sich nicht bloß distributiv erklären, sondern setzt voraus, daß der Schädiger für den Schaden verantwortlich ist; ausführlicher *Jansen*, Tagespolitik, Wertungswandel und Rechtsdogmatik (Fn. 24).

(*culpa*) im Laufe der vielfältigen „Wandlungen“[57] des Haftungsrechts disfunktional geworden sind.

5.1. Zur Entstehung des Haftungsrechts aus dem römischen Deliktsrecht

Diese Begriffe stammen nämlich aus der *actio legis Aquiliae*, die im Römischen Recht die Klage für die Verfolgung von Sachbeschädigungen bildete. Ein Haftungssystem, wie es sich heute in den Rechtsordnungen Europas findet, hat es im Römischen Recht aber nicht gegeben. Heute besteht die Funktion des Haftungsrecht nämlich im gerechten Ausgleich eines Schadens: Das Haftungsrecht fragt, ob ein Schädiger für einen eingetretenen Schaden verantwortlich ist und deshalb dafür haften sollte. Im römischen Deliktsrecht ging es demgegenüber primär um die Frage, ob der Schädiger dem Geschädigten ein Unrecht zugefügt hatte, das dieser rächend vergelten durfte. Sein Fehlverhalten und die Frage nach einer angemessenen Sanktion dafür, nicht ein Ersatzinteresse des Geschädigten standen deshalb im Mittelpunkt des römischen Deliktsrechts.

Besonders deutlich zeigt sich das im Recht der XII Tafeln. Hier findet sich eine Vielzahl systematisch unverbundener Regeln, die jeweils für ein konkretes Delikt eine spezielle Sanktion anordnen: Den auf frischer Tat gestellten Dieb durfte man töten bzw. versklaven (XII T. 8, 14[58]) und eine Körperverletzung ursprünglich durch eine Talion vergelten (XII T. 8, 3). War ein Mensch ohne Absicht getötet worden, so mußte seinem Familienverband ein Sühnewidder gestellt werden (XII T. 8, 24), und je spezifische Regeln galten zum Beispiel auch für die Brandstiftung[59], das Abschneiden von Bäumen (XII T. 8, 11) oder auch für bauliche Maßnahmen auf Grundstücken, die den Ablauf von Regenwasser zum Schaden des Nachbargrundstücks veränderten (XII T. 7, 8)[60].

Nun war es offenbar seit alters üblich, die Talion wegen einer Personenverletzung durch die vergleichsweise Zahlung eines Loskaufgeldes zu vermeiden. Zur Kontrolle bzw. zur Eindämmung ursprünglich unbeschränkter Racherechte wurden dabei aber schon unter den XII Tafeln bestimmte Loskaufsummen, obligatorisch[61]: Bot der Schädiger dem Verletzten eine solche *poena* an, so verlor dieser sein Recht auf eine Talion. Dieser Rechtszustand bildet den Hintergrund für die *lex Aquilia*[62], die in ihrem ersten Kapitel für die Tötung von Sklaven und vierfüßigen Herdentieren die Verpflichtung zur Zahlung einer am Sachwert ausgerichteten *poena* anordnete[63], die jetzt allerdings die unmittelbare Folge des Delikts bildete. Vergleichbar war auch

---

[57] Der Begriff ist von *E. v. Caemmerer* für den letzten Entwicklungsabschnitt im 20. Jahrhundert geprägt worden: Wandlungen des Deliktsrechts, FS zum 100jährigen Bestehen des deutschen Juristentages, 1960, S. 49 ff.

[58] Abkürzungen zum Römischen Recht folgen den üblichen Konventionen, wie sie etwa bei *M. Kaser*, Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt[2], 1971, angegeben sind.

[59] XII T. 8, 10: Bei fahrlässiger Brandstiftung war Schadensersatz geschuldet; im Falle von Vorsatz durfte der Täter getötet werden.

[60] Ausführlicher zum Ganzen *Jansen* (Fn. 1), § 4 I. 1.

[61] XII T. 8, 3-4; siehe dazu *A. Völkl*, Die Verfolgung von Körperverletzungen im frühen römischen Recht, 1984, S. 77 f.; *Kaser*, Privatrecht I[2] (Fn. 58), S. 37 f.

[62] Das Gesetz wurde wahrscheinlich im Jahre 287/86 v. Chr. erlassen; zur strittigen Datierung *Zimmermann*, Obligations (Fn. 53), S. 955 ff. m.w.N.

[63] Genauer: den Höchstwert der Sache im Laufe des letzten Jahres vor der Schädigung; zum Sinn dieser Regelung *Zimmermann*, Obligations (Fn. 53), S. 961 f.; *F.H. Lawson & B.S. Markesinis*, Tortious Liability for Unintentional Harm in the Common Law and Civil Law, vol. I, 1982, S. 5.

für sonstige Sachbeschädigungen durch „Brennen, Brechen oder sonst unmittelbares Beschädigen“ im dritten Kapitel eine entsprechende „Ersatzpflicht“ normiert[64]. Nur scheinbar handelt es sich bei diesen Regeln um ein Schadensersatzgesetz im modernen Sinn: In der Sache ging es vielmehr darum, daß der Geschädigte dem Schädiger zur Vergeltung des erlittenen Unrechts denselben wirtschaftlichen Schaden zufügen durfte, den er erlitten hatte: Die *actio legis Aquiliae* begründet ein Recht auf eine wirtschaftliche Talion[65]. Besonders deutlich zeigen das die Regeln über die Klagekonkurrenz: Hatten mehrere Mittäter einen Schaden verursacht, so hatte jeder dem Geschädigten den vollen Schadensbetrag zu zahlen[66]: Dieser erhielt also einen mehrfachen Ersatz. Denn die *poena* diente zunächst nicht dazu, ihn schadlos zu stellen, sondern sollte eine angemessene Vergeltung für das Fehlverhalten jedes Schädigers leisten. Entsprechendes galt deshalb, wenn ein Schädiger den Sklaven oder das Tier erst verletzt und dann durch eine erneute Handlung getötet hatte: Wieder war sowohl für die Verletzung als auch für die Tötung „Ersatz“ zu leisten[67], ohne daß die Bereicherung des Geschädigten als ein Problem galt.

Nun waren die Begriffe der *iniuria* und der *culpa* für ein solches Institut des privaten Unrechtsausgleichs ausgesprochen funktionsadäquat: Sie beschreiben das sanktionswürdige Verhalten. Dabei war es ursprünglich auch durchaus sachgerecht, daß das private Deliktsrecht damit weniger dem adäquaten Schadensersatz als der angemessenen Sanktion eines Fehlverhaltens dienen sollte. Eine öffentliche Strafverfolgung hat es im alten Rom nämlich nicht gegeben, und der Ausgleich von Unrecht galt deshalb selbstverständlich als eine Privatsache[68]. Dieser Grundsatz der privaten Rechtsverfolgung hat dabei die öffentliche Moral Roms und folglich auch das Deliktsrecht bis zuletzt geprägt. Denn erst unter *Sulla* und im Prinzipat gab es Ansätze zu einer öffentlichen Strafverfolgung, und erst gegen Ende des Dominats war die Verfolgung von Unrecht zu einer Sache (auch) der öffentlichen Hand geworden[69].

Nun ist es durchaus einsichtig, daß der wirtschaftliche Ausgleich von Schäden in einer kleinbäuerlichen Gesellschaft, wie dem alten Rom, als weniger wichtig erscheinen kann als die angemessene Sanktion eines Fehlverhaltens. Unter Augustus war Rom indes zu einer Millionenstadt geworden: Während Wirtschaft und Handel aufgeblüht waren, war es in der römischen Gesellschaft zu erheblichen sozialen Verwerfungen gekommen; private Bindungen vermochten die Gesellschaft nicht länger zu integrieren. Anonyme Verbrechen, die sich zudem häufig nicht aufklären ließen, waren an der Tagesordnung. In Schadensfällen wurde der Schadensausgleich zunehmend wichtiger als die private Sanktion eines Unrechts; der Ersatz eines Schadens bildete entsprechend normalerweise das Motiv für eine Klage nach der *lex Aquilia*. Die klassischen Juristen haben deshalb innerhalb des Rahmens der *actio legis Aquiliae* zunehmend auch den Ersatzinteressen der Kläger Rechnung getragen[70]. Folgerichtig haben sie sich bemüht, im Rückgriff auf das Konzept der *culpa*, das in einer unklaren Weise neben das ältere Konzept der *iniuria* getreten war bzw. dieses ersetzte, individuelle Verantwortungskreise

---

[64] Gai. D. 9, 2, 2 pr.; Ulp. D. 9, 2, 27, 5.
[65] *Jansen* (Fn. 1), § 4 I. 2.1.
[66] Iul. D. 9, 2, 51, 1; Ulp. D. 9, 2, 11, 2 und 4.
[67] Gai. D. 9, 2, 32, 1.
[68] *Jansen* (Fn. 1), § 4 I. 1.3.
[69] Ausführlich zum Ganzen *Jansen* (Fn. 1), § 4 II. 2.
[70] *Jansen* (Fn. 1), § 4 II.

differenziert abzugrenzen[71]. Es war nur sachgerecht, daß man deshalb unter Umständen auch ohne ein eigentliches Fehlverhalten für einen Schaden verantwortlich sein konnte; Ulpian hat dies mit dem Terminus einer leichtesten Fahrlässigkeit (*culpa levissima*) ausgedrückt[72].

Die römischen Juristen haben den Ausgleich von Schäden also konzeptionell im Rahmen der unrechtssanktionierenden *actio legis Aquiliae* geleistet und gerade nicht ein spezifisch haftungsrechtliches Institut für den Schadensausgleich geschaffen. Seinen Grund findet das primär in der verhältnismäßig späten Entwicklung einer öffentlichen Unrechtsverfolgung: Als die Kaiser diese an sich zogen, war es längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, daß die aquilische Klage, zumindest auch, dem angemessenen Schadensersatz dienen sollte[73]. Da die römischen Juristen auf eine derart unrechtssanktionierende Privatklage gar nicht verzichten wollten, haben sie die alten Regeln über die Klagekonkurrenzen nie in Frage gestellt; und wo es paßte, haben sie bis zuletzt mit dem pönalen Charakter der Klage argumentiert[74]: Daß die Sanktion der *actio legis Aquiliae*, die ursprünglich am Sachwert der beschädigten Sache ausgerichtet war, den wirtschaftlichen Schaden des Geschädigten bisweilen nicht voll ersetzte, war für sie ein Problem, das sie rechtsfortbildend bewältigt haben[75]. Zweifel an dem bisweilen mehrfachen „Ersatz“ sind demgegenüber nicht überliefert.

5.2. Auf dem Weg zu einem modernen Haftungsrecht

Die europäischen Juristen des Mittelalters und vor allem des *usus modernus* haben dieses römische Erbe nach und nach in die heutigen Regeln des deliktischen Haftungsrechts umgeformt. Unter der Führung der Gerichte haben sie Schranken der Klage, die sich aus ihrer ursprünglich engen Formulierung ergaben[76], überwunden und die Klage allgemein angewendet, wo sie ein entsprechendes Ersatzbedürfnis gesehen haben. Gleichzeitig haben sie nur pönal erklärbare Regeln, wie die Haftung von Mittätern, schrittweise abgebaut[77] und damit klargestellt, daß sie in der *actio legis Aquiliae* eine Klage für den Schadensersatz, nicht für die Sanktion eines Fehlverhaltens gesehen haben. Die *actio de damno dato* (Schadensersatzklage) wurde damit zu

---

[71] *Zimmermann*, Obligations (Fn. 53), S. 1004 ff.; *U. v. Lübtow*, Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato, 1971, S. 83 ff.; *Jansen* (Fn. 1), § 4 II. 3.3.

[72] Ulp. D. 9, 2, 44 pr.: *in lege Aquilia et levissima culpa venit*; dazu *Jansen* (Fn. 1), § 4 II. 3.3.2.1. Die *actio legis Aquiliae* begründete entsprechend auch eine Haftung für mangelnde Erfahrung (*imperitia*) und auch für einen Mangel an körperlicher Stärke; Gai. D. 9, 2, 8, 1: *infirmitas culpae adnumeratur* (ein Mangel an Kraft wird dem Verschulden zugerechnet). Während dabei die Haftung für *imperitia* sich häufig mit dem Gedanken des Übernahmeverschuldens erklären läßt, ist eine solche Deutung für die Haftung für *infirmitas* nicht möglich. Denn diese Haftung sollte auch Alltagstätigkeiten, wie das Führen eines Maultiers, treffen, von denen man nicht einfach absehen konnte: Es handelt sich um eine objektive, persönliche Verantwortlichkeit für die eigenen Eigenschaften.

[73] *Gaius* hat diese Klage deshalb als eine „gemischte“ (*actio mixta*) bezeichnet (Gai. Inst. 4, 9), die zugleich ein erlittenes Unrecht sanktionieren und einen angemessenen Ersatz gewährleisten solle; ausführlicher dazu *Jansen* (Fn. 1), § 4 II. 3. vor 3.1 m.w.N. zur strittigen Deutung.

[74] *Jansen* (Fn. 1), § 4 II. 3.1 m.w.N.

[75] Iul. D. 9, 2, 51, 2; Ulp. D. 47, 2, 50, 4; Gai. Inst. 3, 202.

[76] So sollte die Klage – als Sachbeschädigungsklage und aufgrund des Gedankens, daß Personenschäden sich finanziell nicht ausgleichen lassen (Gai. D. 9, 3, 7: *liberum corpus nullam recipit aestimationem*) – bei der Verletzung eines freien Menschen nicht anwendbar sein; ebensowenig führten ursprünglich primäre Vermögensschäden einerseits und mittelbare Verletzungen bzw. Unterlassungen andererseits zur Haftung.

[77] Zum Ganzen *G. Rotondi*, Dalla „Lex Aquilia“ all’art. 1151 Cod. Civ., in: *ders*., Scritti Juridici Bd. 2, 1922, S. 465, 501 ff.; *H. Kaufmann*, Rezeption und Usus Modernus der Lex Aquilia, 1958, *passim*, besonders S. 46 ff., 104 ff.; *Zimmermann*, Obligations (Fn. 53), S. 1018 ff.; *Jansen* (Fn. 1), § 5 II. 1. und 2.

einer umfassenden „zivilrechtlichen Generalklausel“[78].

Entsprechend haben die Juristen die Haftung bis zur *culpa levissima* besonders hervorgehoben, und sie haben mit den Beispielen dafür deutlich gemacht, daß damit nicht ein – vielleicht läßliches – Fehlverhalten, sondern eine fehlverhaltensunabhängige Haftung bezeichnet sein sollte[79]. Der spanische Spätscholastiker *Molina*, dessen Lehre insoweit von den Autoren des *usus modernus* unmittelbar rezipiert worden ist[80], hatte dies auch theoretisch klar erläutert: Bisweilen sei es durchaus erlaubt, gefährlichen Tätigkeiten nachzugehen, die Risiken für die Rechtsgüter anderer mit sich brächten; unzulässig sei es aber, derartige Tätigkeiten zu unternehmen, ohne bereits zu sein, im Schadensfall die Geschädigten schadlos zu stellen[81]. Dies werde durch die *culpa levissima* ausgedrückt: Sie sei nicht eine Haftung für ein verbotenes Verhalten sondern beruhe auf dem vertragsähnlichen Gedanken einer stillschweigenden Risikoübernahme[82]. Dogmatisch handelt es sich also um eine fehlverhaltensunabhängige Garantiehaftung; das Erfordernis, daß der Schaden *iniuria*, also rechtswidrig, herbeigeführt sein mußte, ließ sich insoweit nur im Sinne eines rein erfolgsbezogenen Rechtswidrigkeitsbegriffs verstehen: *iniuria* bezeichnete hier nicht ein rechtswidriges Verhalten sondern die Verletzung eines absoluten subjektiven Rechts[83].

Die *actio de damno dato* bot damit eine einheitliche Anspruchsgrundlage für sämtliche zurechenbare Verletzungen individuell zugewiesener Rechtsgüter; fehlverhaltensunabhängige Haftungstatbestände waren damit neben dieser Klage an sich überflüssig. Daß all dies mit der ursprünglichen *actio legis Aquiliae* wenig mehr als den Namen gemein hatte, war dabei den Juristen des *usus modernus* auch durchaus bewußt[84]. *Christian Thomasius* wollte deshalb sogar der *actio de damno dato* die „aquilische Maske herunterreißen“[85]; dies hätte eine grundlegende konzeptuelle und terminologische Reform des Haftungsrechts bedeutet, für die angesichts der

---

[78] *S. Stryk*, Specimen usus moderni pandectarum (Halae Magdeburgicae 1723), *lib*. IX, *tit*. II, § 1: *tituli praesentis usus amplissimus est, cum omnium damnorum reparatio ex hoc petatur, si modo ulla alterius culpa doceri possit* (der Anwendungsbereich dieses Titels ist außerordentlich weit, denn daraus wird der Ersatz jeden Schadens geltend gemacht, sofern sich nur irgendein Verschulden eines anderen nachweisen läßt).

[79] Fallenlassen einer Teetasse aufgrund des Erschreckens über einen Schuß (*N.H. Gundling*, Discourse über Die sämtlichen Pandecten, Frankfurt und Leipzig 1748, *lib*. IX, *tit*. II, § 2), Betreten des Heubodens mit einer Lampe, auch dann wenn diese aufs Beste verwahrt sei (*L.J.F. Höpfner*, Theoretisch-practischer Kommentar über die Heineccischen Institutionen[8], bearbeitet von *A.D. Weber*, Frankfurt a.M. 1818, §§ 757, 758); hierzu und zum folgenden *Jansen* (Fn. 1), § 5 II. 3.2 m.w.N.

[80] Siehe nur die Verweise bei *G.A. Struve*, Syntagma jurisprudentiae secundum ordinem Pandectarum concinnatum, con additionibus *P. Mülleri* (Francofurti & Lipsiae 1738), D. 9, 2, *erxerc*. XIV, § 20; *J. Brunnemann*, Commentarius in Pandectas (Coloniae Allobrogum 1752), zu D. 9, 2, 44, Rn. 1 und 5.

[81] *L. Molina*, De iustitia et iure (Moguntiae 1659), *tract*. II, *disp*. 698, Rn. 3 f.; vgl. auch *R.P.L. Lessius*, De iustitia et iure (Venetiis 1734), *lib*. II, *cap*. VII, *dub*. VI.

[82] *…ratione pacti seu quasi pacti*: *Molina*, iustitia (Fn. 81), *disp*. 698, Rn. 3.

[83] *Jansen* (Fn. 1), § 5 II. 3.2, III. 2.3.

[84] Manche Autoren hatten deshalb die *actio legis Aquiliae* für abgeschafft gehalten und die *actio de damno dato* auf einheimisches Recht gestützt; z.B. *J. Schilter*, Praxis Iuris Romani in Foro Germanico (Francofurti et Lipsiae 1713), *exerc*. XIX, 67; *Höpfner*, Kommentar (Fn. 79), § 1060; andere wollten die Fahrlässigkeitshaftung bei den strikten, fehlverhaltensunabhängigen Quasidelikten einordnen: *J.G. Heineccius*, Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum (Lipsiae 1766), §§ 1034, 1081; *ders*., Recitationes in Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum (Leovardiae et Franquerae 1773), § 1112; *W.A. Lauterbach*, Collegium theoretico-practicum (Tubingae 1734), *lib*. IX, *tit*. II, § 3 und *lib*. XLVII, *tit*. I, § 8.

[85] So der Titel der Dissertation, Larva legis Aquiliae detracta actioni de damno dato (Halae Magdeburgicae 1720, neu hg. von *M. Hewett*, 2000); *Thomasius* hat die Dissertation wahrscheinlich selbst verfaßt: *R. Zimmermann*, Christian Thomasius, the Reception of Roman Law and the History of the Lex Aquilia, in: *Thomasius*, a.a.O., S. 49, 68.

erheblichen funktionalen Wandlungen des Delitksrechts einiges gesprochen hätte.

5.3. Das Haftungsrecht in der naturrechtlichen Diskussion

Zu einer solchen Reform ist es allerdings nicht gekommen. Seinen Grund findet das zum einen in der Tatsache, daß für die an abstrakten dogmatischen Fragen nicht interessierte herrschende Lehre des *usus modernus* eine derartige Reform nicht angezeigt war, solange es möglich war, sich pragmatisch mit dem überlieferten Römischen Recht zu akkomodieren. Hinzu kam – langfristig war das wesentlich folgenträchtiger –, daß die naturrechtliche Systembildung die Sanktionsorientierung des Deliktsrechts, also seine konzeptionelle Bindung an die Verletzung bürgerlicher Verhaltenspflichten, in einem besonderen Maße verfestigt hat.

Grotius, dessen Lehre noch unmittelbar von spätscholastischen Autoren wie *Molina* und *Lessius* beeinflußt ist, bietet hier noch ein abivalentes Bild: In seinem privatrechtlichen Hauptwerk, der *Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyd*, ist die Haftpflicht teleologisch auf den Schutz individuell zugewiesener Rechtspositionen (Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre und Eigentum) und auf die persönliche Verantwortlichkeit für einen Schaden bezogen[86]; entsprechend hat er sich deshalb auch für eine Ausweitung der strikten quasideliktischen Haftung und für eine Aufopferungshaftung ausgesprochen[87]. Diese Wertung ist im europäischen Rechtsdenken bis heute präsent geblieben; deutlich formuliert haben sie – im einzelnen mit erheblichen konzeptionellen Unterschieden – Autoren wie *Thomasius*[88], *Kant*[89], *von Zeiller*[90], der englische Richter Baron *Bramwell*[91] und der belgische *Procureur Général Leclercq*[92]; im 20. Jahrhundert stehen dafür in Frankreich *Boris Starck*[93], in England *Tony Honoré*[94] und in Amerika *Richard Epstein*[95]. Gedanklich trägt diese Wertung offenbar auch die fehlverhaltensentkoppelte Verkehrspflichtenrechtsprechung[96]; und sie vermag ganz allgemein eine geeignete Grundlage für fehlverhaltensunabhängige Haftungstatbestände zu bieten[97].

Für die dogmatische Systembildung folgenträchtiger war freilich *Grotius'* Deliktsrechtstheorie in seinem naturrechtlichen Hauptwerk *De iure belli ac pacis*[98]. Dort bildet die Haftung nämlich konzeptionell die Folge der Verletzung einer zwischenmenschlichen Verhaltenspflicht; teleologisch steht deshalb der Verschuldensgrundsatz im Zentrum des Haftungsrechts – bereits

---

[86] *H. Grotius*, Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerheyd, neu hg. von *R.W. Lee*, 1926, *boeck* II, *deel* 32 ff.; siehe zum Ganzen *Jansen* (Fn. 1), § 5 III. 3.2.
[87] *Grotius*, Inleiding (Fn. 86), II, 32, §§ 22 f.; vgl. auch *dens*., De iure belli ac pacis libri tres (Amsterdami 1642), *lib*. II, *cap*. II, §§ 6, 9, *lib*. III, *cap*. XII, § 1 (Rn. 1).
[88] *Thomasius*, Larva legis Aquiliae (Fn. 85), §§ 2, 10; dazu *Jansen* (Fn. 1), § 5 IV. 2.2.
[89] *I. Kant*, Metaphysik der Sitten[2], Königsberg 1798, S. 97.
[90] *F. v. Zeiller*, Das natürliche Privat-Recht[3], Wien 1819, §§ 4 ff., 49, 179.
[91] Siehe etwa *Bamford* v *Turnley* (3 B & S 62, 84 f., 122 ER, 25, 27, 33) und *Brand* v *Hammersmith and City Railway Co.* ((1867) LR 2 QB 223, 230 ff.)
[92] Dazu *A. Tunc*, Introduction, IECL XI/I, 1983, Kap. 1, Rn. 175 m.w.N.
[93] *B. Starck*, Domaine et fondement de la responsabilité sans faute, RTD civ. LVI (1958), S. 475, 501 ff.: eine „Garantietheorie" subjektiver Rechte als Grundlage einer strikten Haftung.
[94] *T. Honoré*, Responsibility and Fault, 1999; dazu *Jansen* (Fn. 1), § 2 III. m.w.N.
[95] *R. Epstein*, A Theory of Strict Liability, *JLSt*. 2 (1973), 151 ff.; dazu *Jansen* (Fn. 1), § 2 II. 2.
[96] *E. Steffen*, Verkehrspflichten im Spannungsfeld von Bestandsschutz und Handlungsfreiheit, VersR 1980, S. 409, 410: „Schutzpositionen für den Schadensausgleich"; *Jansen* (Fn. 1), § 8 II. 3.1.
[97] *Jansen* (Fn. 1), § 2 III. 2., § 9 II. 2.
[98] *Grotius*, De iure belli ac pacis (Fn. 87), *lib*. II, *cap*. XVII.

für *Pufendorf* bildet er ein Axiom[99]. Seit Pufendorf hatte die herrschende Naturrechtslehre das Privatrecht nämlich mit zunehmender Selbstverständlichkeit als eine bürgerliche Pflichtenordnung konzipiert, und in einem solchen System liegt es nahe, die Haftpflicht als die Sanktion der Verletzung einer solchen Pflicht zu verstehen[100]. Strukturell unterscheidet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz dann nicht von der Auferlegung einer (öffentlichen) Strafe; und wieder erscheinen in einem derart sanktionsorientierten Modell die fehlverhaltensbezogenen Begriffe der Rechtswidrigkeit und des Verschuldens ausgesprochen funktionsadäquat. Von spezifisch haftungsrechtlichen Überlegungen – dies ist hier besonders zu betonen – war diese Entwicklung allerdings nicht getragen. Vielmehr war sie allein von dem Bestreben geleitet, ein systematisch einfaches und geschlossenes System des Privatrechts zu formulieren; dafür bildet die Reduktion des Rechts auf eine Ordnung zwischenmenschlicher Verhaltenspflichten ja in der Tat einen geeigneten Ansatz.

Für die fehlverhaltensunabhängigen Risikozuweisungen, die sich mittlerweile für einen fairen Schadensausgleich als unverzichtbar erwiesen haben und die ja auch in die Praxis des *usus modernus* Eingang gefunden hatten, war in solchen Systemen freilich kein Platz. Entsprechend wurde die *culpa levissima* der Praxis entweder übergangen oder als ein echtes Fehlverhalten (um)gedeutet[101]; eine strikte Haftung mußte deshalb als ein Unding erscheinen[102]. Seine maßgebliche Formulierung hat dieses Verständnis des Deliktsrechts schließlich bei *Christian Wolff* gefunden, der damit die naturrechtlichen Kodifikationen einerseits und die pandektistische Lehre des 19. Jahrhunderts andererseits maßgeblich beeinflussen sollte[103].

5.4. Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert

Dieses sanktionsorientierte Verständnis des Haftungsrechts paßt nämlich in besonderer Weise zu dem römischen Deliktsrecht, das ja ebenfalls der Sanktion von Unrecht dienen sollte. Es verwundert deshalb nicht, daß die pandektistische Rechtslehre, deren wissenschaftlicher Anspruch gleichermaßen von Quellentreue und systematischer Schlüssigkeit bestimmt war, sich diese Konzeption des Naturrechts ohne weiteres zu eigen gemacht hat[104]. Für die *culpa levissima* war in den pandektistischen Systemen deshalb kein Platz mehr[105], und die Fahrlässigkeitshaftung sollte keinesfalls über tatsächlich vernünftige Sorgfaltspflichten hinausgehen[106]. Vielfach wurden sogar die römischen Privatstrafen als geltendes Recht

---

[99] *S. Pufendorf*, De iure naturae et gentium libri octo, Francofurti et Lipsiae 1759, *lib.* I, *cap.* V, § 5: *axioma in moralibus*.

[100] Ausführlich *Jansen* (Fn. 1), § 5 IV. 1. und 3.; führend waren dabei insbesondere *Pufendorf* und *Christian Wolff*.

[101] *Pufendorf*, De iure naturae (Fn. 99), *lib.* I, *cap.* V, § 15 a.E.; vgl. auch *lib.* I, *cap.* VII, § 16 und *lib.* III, *cap.* I, § 6; zu diesem Teilstück der Theorie Pufendorfs *Jansen* (Fn. 1), § 5 IV. 1.2.

[102] *S. Pufendorf*, De officio hominis et civis, Cantabrigae 1682 (neu hg. von *K. Luig*, Über die Pflicht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur, 1994), *lib.* I, *cap.* VI, § 10; soweit Pufendorf, entsprechend der Praxis seiner Zeit, strikte Tatbestände anerkannt hat, hat er zur Begründung lediglich auf die Billigkeit (*aequitas*) verwiesen, ohne dies näher zu erläutern: a.a.O., *lib.* I, *cap.* V, § 24, *cap.* VI, §§ 11.

[103] Ausführlicher zum Ganzen *Jansen* (Fn. 1), § 5 IV. 3.

[104] Freilich haben die Mitglieder der Historischen Schule sich nicht unmittelbar auf naturrechtliche Theorien bezogen, weil sie deren quellenfernen Ansatz prinzipiell abgelehnt haben; zum Ganzen etwa *F. Wieacker*, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit[2], 1967, S. 348 ff., 367 ff.; *R. Zimmermann*, Roman Law, Contemporary Law, European Law, 2001, S. 11 ff.

[105] Nach *A.J.F. Thibaut*, System des Pandekten-Rechts I[6], 1823, § 253, grundlegend *J.C. Hasse*, Die Culpa des Römischen Rechts[2], Bonn 1838, S. 4, 65 ff., 90 ff.

[106] *Fr. Mommsen*, Die Lehre von der *mora* nebst Beiträgen zur Lehre von der *culpa*, Braunschweig 1855, S. 361 ff.,

dargestellt[107], und *von Jhering* bemühte sich in seinem berühmt gewordenen *Schuldmoment des römischen Privatrechts* um den Nachweis des axiomatischen Charakters des Verschuldensgrundsatzes[108]: Der Grundsatz, daß nur das Verschulden eine Haftpflicht begründen könne, sei so evident wie der Satz, daß eine Flamme auf Sauerstoff angewiesen sei. Bei dem dabei vorausgesetzten Verständnis der Haftpflicht als Sanktion („kein Uebel ohne Schuld"[109]) war das in der Tat plausibel.

Freilich hatte sich mittlerweile längst erwiesen, daß ein derart konsequent verstandener Verschuldensgrundsatz für einen angemessen Schadensausgleich keine abschließende Wertung bot. Der preußische Gesetzgeber hatte bereits 1838 zugleich mit der Inbetriebnahme der ersten Eisenbahn eine Gefährdungshaftung für diese angeordnet[110]; maßgeblich war dabei der Staatsrat *Friedrich Carl von Savigny*[111], auf dessen wissenschaftliche Tätigkeit das freilich ohne Einfluß geblieben ist[112]. 1871 wurde dieser Haftungstatbestand dann mit dem Reichshaftpflichtgesetz für das gesamte Reich verbindlich; bereits seit 1864 galt eine strikte Haftung im Bergwerksgesetz; und die Versicherungslösung für Arbeitsunfälle gilt seit 1884.

Damit ist die Entwicklung zu dem „zweispurigen" System des Haftungsrechts angelegt, wie es heute gilt: Das klassische bürgerliche Deliktsrecht wird im Sinne des römischen Rechts und der naturrechtlichen Systembildung als Sanktion einer Pflichtverletzung konzipiert – im BGB sind die §§ 823 ff. entsprechend mit dem naturrechtlichen Terminus „Unerlaubte Handlungen" überschrieben[113]. Wo dies zu inakzeptablen Ergebnissen führt, sollen ergänzend Gefährdungshaftungstatbestände hinzutreten, die aber als systemfremd in Sondergesetzen ausgegrenzt werden. Dies hat allerdings zu einer außerordentlich zersplitterten und auch inkonsistenten Regelung der Gefährdungshaftung geführt[114]; und daß diese dabei im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, hat offenbar nichts daran geändert, daß viele sie nach wie vor als eine systemfremde, nicht analogiefähige Anomalie begreifen[115]. Daß das zweispurige System nicht zur einheitlichen Wertungsstruktur des Haftungsrecht paßt, ist nie zum Problem geworden[116].

---

367 ff.; aus der Lehrbuchliteratur *L. Arndts R. v. Arnesberg*, Lehrbuch der Pandekten[14], Stuttgart 1889, § 86 (S. 144); *G.F. Puchta*, Pandekten[9], Leipzig 1863, § 266 (S. 408 f.); *C.G. v. Wächter*, Pandekten I, Leipzig 1880, § 87 (S. 446 f.); *B. Windscheid/T. Kipp*, Lehrbuch des Pandektenrechts I[8], 1906, § 101 (S. 521 f.); weitere Nachweise bei *Jansen* (Fn. 1), § 7 Fn. 278.

[107] Siehe etwa *Thibaut*, Pandekten (Fn. 105), §§ 66 ff., 68 (S. 52 ff.); *Puchta*, Pandekten (Fn. 106), §§ 230, 261 (S. 356, 403); weitere Nachweise bei *Jansen* (Fn. 1), § 6 I.

[108] *R. v. Jhering*, Das Schuldmoment des römischen Privatrechts, 1867, S. 40 ff. und *passim*.

[109] *v. Jhering*, Schuldmoment (Fn. 108), S. 8, 60 ff.

[110] § 25 des Eisenbahngesetzes; dazu etwa *Zimmermann*, Obligations (Fn. 53), S. 1131 m.w.N.

[111] *T. Baums*, Die Einführung der Gefährdungshaftung durch F.C. von Savigny, ZSS (germ.) 104 (1987), S. 277 ff.

[112] *Savigny* hat weder in seinem *System des heutigen römischen Rechts* noch in seinem *Obligationenrecht* die Gefährdungshaftung auch nur angesprochen, und die Quasidelikte behandelt er höchst kursorisch: Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts II, Berlin 1853, S. 3, 330 f.

[113] Der Begiff geht auf *Christian Wolff* zurück: Grundsätze des Natur- und Völckerrechts, Halle 1754, §§ 87, 88.

[114] Statt aller *Kötz*, Besondere Gefahr (Fn. 13), S. 14 ff.; *Zimmermann*, Obligations (Fn. 53), S. 1134 f.

[115] So beurteilt *Canaris* die Gefährdungshaftung nach wie vor als „rechtsethisch unterlegen": Die Gefährdungshaftung im Licht der neueren Rechtsentwicklung, JBl. 1995, S. 2, 16; *Larenz/Canaris*, SchuldR II/2 (Fn. 3), S. 608 f.; ausführlicher dazu *Jansen* (Fn. 1), Einleitung I. 3.2 m.w.N.

[116] Zwar hat es gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Grundlagendiskussion gegeben, die den Verschuldensgrundsatz in Frage gestellt hat (*Jansen* (Fn. 1), § 6 IV). Die Möglichkeit eines einheitlichen Haftungssystems, das die Haftung nur bei einem Fehlverhalten, etwa bei Alltagstätigkeiten, systematisch mit Fällen einer strikten Haftung verbinden kann, ist dabei aber offenbar nicht in den Blick gekommen.

Vielmehr hat die herrschende zivilrechtliche Lehre sich primär darum bemüht, die fehlverhaltensorientierte Regelung des BGB systematisch und begrifflich konsequent fortzuentwickeln; nach dogmatischen Alternativen zu diesem Verständnis wurde nicht gefragt: Dies erklärt beispielsweise auch die Diskussion um den Rechtswidrigkeitsbegriff in den 70er und 80er Jahren[117]: Ein erfolgsbezogener Rechtswidrigkeitsbegriff würde zu dem gesetzgeberischen Ziel eines effektiven Rechtsgüterschutzes und der ursprünglichen Konzeption des BGB passen[118]; das herrschende verhaltensbezogene Konzept[119] entspricht dem sanktionsorientierten System. Folgerichtig sollte für *von Caemmerer* im Deliktsrecht die Hauptaufgabe darin bestehen, „die Verhaltensnormen herauszuarbeiten, an deren Verletzung eine Schadensersatzpflicht geknüpft werden soll"[120]; und besonders konsequent hat dieses Verständnis des Deliktsrechts dann *Rödig* zu Ende gedacht: Die in § 823 II BGB angeordnete Haftung für die Verletzung einer Rechtspflicht bilde den eigentlichen Grundtatbestand des Haftungsrechts, und § 823 I BGB sei angesichts dessen nicht mehr als eine kurzformelartige Beschreibung verbotener Verhaltensweisen[121].

6. Ein alternatives Modell

Nun hat sich mittlerweile gezeigt, daß dieses Verständnis des Delikts- bzw. des Haftungsrechts in die Irre führt: Probleme fairer Risikozuweisungen sind gerade nicht auf außergewöhnlich Gefährliches beschränkt; und die Aufgabe der Rechtswissenschaft besteht deshalb ganz allgemein nicht in der Formulierung einer bürgerlichen Pflichtenordnung sondern in der sachgerechter Beschreibung von haftungssteuernden Wertungen, die regelmäßig auch fehlverhaltensentkoppelt erfolgen.

Ein solches System soll zugleich die tatsächlich haftungssteuernden Wertungen angemessen beschreiben und mittels klarer Tatbestände der Rechtsprechung deutliche Entscheidungsvorgaben bieten. Dabei sollte es aber auch, soweit dies möglich ist, an das historisch überlieferte Haftungssystem anknüpfen. Denn eine solche historische Anknüpfungsfähigkeit ist sowohl für die Akzeptanz als auch für die einfache Verständlichkeit eines neuen Systems unabdingbar[122]. Ich habe für ein solches System ein Modell vorgeschlagen, dessen Grundgedanke in der Haftung für die Verletzung rechtsgutsbezogener Haftungsobliegenheiten besteht[123].

Dieses Modell beruht auf der Annahme, daß die zurechenbare Verletzung eines fremden

---

[117] Ausführlicher zum folgenden *Jansen* (Fn. 1), § 7 II. 3.1.

[118] vgl. *F.P. v. Kübel*, Recht der Schuldverhältnisse Teil 1. Allgemeiner Teil, hg. v. *W. Schubert*, Die Vorentwürfe der Redanktoren für die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs, 1980, S. 663 (Unerlaubte Handlungen, S. 7); siehe auch *A. v. Tuhr*, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Bd. II/2, 1918, S. 453 ff.; *Jansen* (Fn. 1), § 7 II. 2. m.w.N.

[119] Auch nach der Lehre vom Erfolgsunrecht soll ja nicht der Erfolg an sich, sondern das rechtsgutsgefährdende Verhalten rechtswidrig sein; vgl. etwa *Deutsch*, Haftungsrecht (Fn. 3), Rn. 237 m.w.N.

[120] *E. v. Caemmerer*, Die absoluten Rechte in § 823 Abs. 1 BGB, Karlsruher Forum 1961, S. 19; siehe auch *dens.*, Wandlungen (Fn. 57), S. 75 ff., 127 ff., 131.

[121] *J. Rödig*, Erfüllung des Tatbestandes des § 823 Abs. 1 BGB durch Schutzgesetzverstoß, 1973, S. 56 ff., 78 ff.

[122] Ausführlicher zu den Anforderungen an eine adäquate Systembildung *Jansen* (Fn. 1), § 9 I. 1.

[123] *Jansen* (Fn. 1), § 9, II.-VI.; für eine regelförmige Formulierung eines solchen Systems als *restatement* des geltenden Rechts siehe § 9 VII.

Rechtsguts *prima facie* einen Grund dafür bietet, den entstandenen Schaden zu ersetzen. Dieser Gedanke des möglichst umfassenden Schutzes individuell zugewiesener Rechtspositionen[124] ist in der Geschichte des Haftungsrechts seit der neuzeitlichen Reformulierung des Römischen Rechts stets präsent gewesen[125], und er bildet heute eine fundamentale gemeineuropäische Wertüberzeugung[126]. Freilich kann die Verantwortlichkeit für eine fremde Rechtsgutsbeeinträchtigung nicht stets zu einer Haftpflicht führen, denn dies würde auf eine inakzeptabel umfassend strikte Haftung hinauslaufen. Ob letztlich der Geschädigte oder der Schädiger den Schaden zu tragen haben, beruht deshalb erst auf der Abwägung einer Vielzahl einschlägiger, häufig gegenläufiger Haftungsprinzipien, die ein „bewegliches System" des Haftungsrechts bilden[127]; Beispiele sind das Verschuldensprinzip einerseits, wonach eine Haftpflicht grundsätzlich nur bei einem Fehlverhalten zumutbar ist, und der Gefährdungsgrundsatz andererseits, der zu einer strikten Haftung für besondere Gefahren führt; daneben stehen etwa die Prinzipien der besseren Versicherbarkeit, des besonderen Schutzes von Kindern, der strikten Unternehmenshaftung und der Entlastung von Alltagstätigkeiten sowie eine angemessene Schadensprävention. Derartige Prinzipien können in einem konkreten Fall zugleich einschlägig sein; ihre Abwägung bestimmt dann den Haftungsmaßstab. Bestimmte Erwägungen sollten dabei freilich von Rechts wegen abstrakt ausgeschlossen sein. Insbesondere sollte die Berücksichtigung aktueller Vermögensverhältnisse und entsprechend auch die Tatsache des Versichertseins bei einer Haftungsentscheidung keine Rolle spielen dürfen[128].

Je nach den Gewichten der konkret einschlägigen Prinzipien muß die Haftung folglich mehr oder weniger strikt ausfallen. Ein angemessenes Modell verlangt deshalb einen Katalog graduell abgestufter Haftungsmaßstäbe, die etwa von der absoluten Haftung über die Haftung bis zur höheren Gewalt und die verschärfte Sorgfaltshaftung (beim Haftungsausschluß des unabwendbaren Ereignisses) bis zur Fahrlässigkeitshaftung und zur eingeschränkten Haftung, etwa nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, reicht[129]. In einem solchen Modell sollten die – teilweise ja von fehlverhaltensunabhängigen Wertungen begründeten – haftungsbeschreibenden Sorgfaltsmaßstäbe nicht als tatsächliche Verhaltensanforderungen, sondern als *Haftungsobliegenheiten* begriffen werden: Sie besagen nicht, welche Rücksicht im Rechtsverkehr tatsächlich geschuldet ist, sondern welche Sorgfalt von der Haftpflicht entbindet[130]. Derartige Haftungsobliegenheiten knüpfen an die entwickelte Dogmatik zur Fahrlässigkeitshaftung an, so daß beispielsweise die Normzwecklehre weiterhin einen Platz im Haftungsrecht hat. Sie überwinden aber die irreführende Gleichsetzung von Haftungsmaßstäben und Verhaltensanforderungen im gegenwärtigen Recht.

Nun könnte die bloße Angabe von Prinzipien der Rechtsprechung keine klaren Entscheidungsvorgaben bieten, zumal diese ja häufig sehr allgemein und unspezifisch sind. Aus diesem Grunde ist eine Reihe von Beispielsfällen erforderlich, die den jeweiligen

---

[124] *Jansen* (Fn. 1), § 2 II. 2.1, § 5 IV. 2.
[125] *Jansen* (Fn. 1), § 5 III.
[126] Siehe die Nachweise oben Fn. 86, 88 ff.
[127] *Jansen* (Fn. 1), § 9 IV., VI., auch zu den Rationalitätskriterien und der intersubjektiv verständlichen Beschreibung von Abwägungen.
[128] *Jansen* (Fn. 1), § 9 VI. 2.
[129] *Jansen* (Fn. 1), § 9 I. 3., V.
[130] *Jansen* (Fn. 1), § 9 V. 3.; siehe bereits *Jansen*, Rechtswidrigkeit (Fn. 38), S. 546 ff.; *ders.*, Auf dem Weg zu einem europäischen Haftungsrecht, ZEuP 9 (2001), S. 30, 57 f.

Haftungsmaßstäben zugeordnet werden. Zum einen bieten diese feste, regelförmige Entscheidungsvorgaben. Wichtiger ist aber, daß derartige Beispiele zugleich eine indirekte, intersubjektiv klar verständliche Aussage über die Gewichte der einzelnen Haftungsprinzipien treffen. Diese werden dadurch für die Rechtsprechung anwendbar. Die Angabe der einschlägigen Haftungsprinzipien dient also der Wertungsangemessenheit des Modells: Sie erlaubt es, die entscheidungsleitenden normativen Gesichtspunkte ausdrücklich anzusprechen. Die Beispiele gewährleisten demgegenüber das Erfordernis klarer Entscheidungsvorgaben und machen damit das wertungsangemessene „bewegliche System" für die Praxis handhabbar.

Neben dem Haftungsausschluß aufgrund der Beachtung der haftungsbefreienden Sorgfalt steht freilich eine Gruppe andersartiger Ausschlußtatbestände[131], die – wie die Notwehr oder die Einwilligung – bislang als Rechtfertigungsgründe diskutiert werden. Dieses Verständnis bildet die Konsequenz der einseitig schädigerorientierten, am Fehlverhalten ausgerichteten bisherigen Deliktsrechtsdogmatik. Daß diese jedoch inadäquat ist zeigt sich hier besonders deutlich. Denn einerseits können die „Rechtfertigungsgründe" auch eine Gefährdungshaftung ausschließen, obgleich es für die Gefährdungshaftung gar nicht auf eine Rechtswidrigkeit ankommt[132]; und andererseits bleibt die Haftpflicht von manchen, allein die Interessen des Schädigers berücksichtigenden Rechtfertigungsgründen unberührt. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür bietet der im offensiven Notstand erlaubte Eingriff in fremde Rechtsgüter. Nicht die Erlaubnis des Eingriffs entbindet in diesen Fällen von der Haftung, sondern die rechtliche Entwertung der Schutzposition des Geschädigten, die entweder auf seiner Disposition (Einwilligung), oder darauf beruht, daß das Recht ihm den Rechtsgüterschutz entzieht (Notwehr, defensiver Notstand). Ein solcher Haftungsausschluß beruht also gerade nicht auf einer Bewertung des schädigenden Verhaltens (Rechtfertigung), sondern auf einer Beurteilung der Schutzwürdigkeit des Geschädigten. Die Aufopferungshaftung bildet deshalb nicht länger eine schwer erklärliche „haftungsrechtliche Anomalie"[133], sondern ein folgerichtiges Teilstück in einem Haftungsmodell, das nicht von der Sanktion eines Fehlverhaltens, sondern von der persönlichen Verantwortlichkeit für einen Schaden ausgeht.

Insgesamt kann ein solches Modell beanspruchen, das tatsächlich geltende Haftungsrecht, wie es sich aus den Entscheidungen der Rechtsprechung ergibt, adäquater zu beschreiben, als dies die derzeitige Dogmatik des Haftungsrechts leistet. Hinzuzufügen ist dabei freilich – dies knüpft an den einleitend formulierten Vorbehalt an –, daß ein solches Modell um einen Tatbestand wie § 823 II BGB zu ergänzen ist, der die Haftung nicht mit dem Schutz eines individuell zugewiesenen Rechtsguts, sondern mit der Verletzung einer Rechtspflicht begründet. Denn die Verletzung einer haftungsunabhängig begründbaren Rechtspflicht zieht grundsätzlich die Verantwortlichkeit für einen daraus resultierenden Schaden nach sich. Die Haftung beruht hier nicht auf dem berechtigten *gegenstandsbezogenen* Vertrauen in die Integrität bestimmter Rechtsgüter bzw. absoluter subjektiver Rechte, sondern auf dem *verhaltensbezogenen* Vertrauen, daß andere sich gesetzestreu verhalten und nicht den Interessen anderer rechtswidrig zuwiderhandeln[134].

---

[131] *Jansen* (Fn. 1), § 9 III. 1.
[132] *v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn. 6), Rn. 488; *Wagner*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht (Fn. 6), V. 1. b; *Jansen*, Europäisches Haftungsrecht (Fn. 130), S. 44 f.
[133] So *v. Bar*, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II (Fn. 6), Rn. 502.
[134] Jansen (Fn.), § 1 II. 2.3, § 9 I. 4.4.